

<제1장 노동법 총론.제3절 근로기준법의 적용범위>

I. 전부적용

1. 상시 5인 이상의 근로자의 사용

(1) 상시 근로자 수 산정의 원칙

- 근로기준법은 원칙적으로 상시 5인 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 전부 적용된다. 여기서 상시라 함은 상태를 의미하며, 근로자 수가 때때로 5인 미만인 상태라도 상정적으로 보아 5인 이상이면 족하다. 산정 방법은 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 중의 가동 일수로 나누어 산정한다.

(2) 근로자의 범위

- 상시 근로자 수 산정 시 포함되는 근로자는 근로계약의 형식과 관계없이 실질적으로 근로기준법상 근로자에 해당하는 모든 인원을 포함한다. 따라서 기간제 근로자, 단시간 근로자, 일용직 근로자 등 고용 형태를 불문하며, 외국인 근로자나 불법 체류 근로자도 산정 인원 포함된다. 다만, 사용자의 동거 가족만을 사용하는 경우나 가사 사용인은 적용 제외 대상이므로 산정 인원에서 제외된다.

2. 사업 또는 사업장

(1) 사업의 정의

- 사업이란 일정한 목적을 위하여 유기적인 조직 하에 지속적으로 행해지는 경제적·사회적 활동의 단위를 의미한다. 영리 목적 여부는 불문하며, 비영리 재단법인, 종교단체, 교육기관 등도 근로자를 사용하여 사업을 영위한다면 근로기준법의 적용 대상이 된다.

(2) 사업장의 장소적 관념

- 사업장은 사업이 행해지는 구체적인 장소를 의미한다. 하나의 사업이 장소적으로 분리되어 있는 경우 원칙적으로는 각 사업장별로 상시 근로자 수를 산정하여 법 적용 여부를 결정한다. 다만, 장소적으로 분리되어 있더라도 인사·회계·노무관리 등이 본사에서 통합적으로 관리되어 독립성이 없는 경우에는 전체를 하나의 사업으로 보아 합산 산정한다.

3. 구체적 사례 : 근로기준법 적용 여부

(1) 국가 및 지방자치단체

- 국가나 지방자치단체도 근로자를 사용하는 사업주로서 근로기준법의 적용을 받는다. 소속 공무원이 국가공무원법 등 특별법의 우선 적용을 받으나, 공무원이 아닌 신분의 현업 근로자나 기간제 근로자 등은 근로기준법의 전면적인 적용 대상이다.

(2) 법인격이 없는 단체

- 친목 도모를 위한 모임이나 법인 등록이 되지 않은 단체라 하더라도, 실질적으로 노무를 제공받고 임금을 지급하는 종속적인 근로관계가 형성되어 있다면 근로기준법상 사업주로서 의무를 진다.

II. 일부적용

1. 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 적용되는 규정

(1) 일부 적용의 법적 근거

- 근로기준법 제11조 제2항 및 동법 시행령 별표 1에 따라 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에는 법의 일부 규정만이 적용된다. 이는 소규모 사업장의 영세성과 행정적 부담을 고려한 예외적인 조치이다.

(2) 주요 적용 규정

- 소규모 사업장이라 하더라도 근로자의 기본적인 생존권 보호를 위해 다음과 같은 핵심 규정은 적용된다. 근로조건의 명시 및 서면 교부 의무, 임금 지급의 4대 원칙(통화불·직접불·전액불·정기불), 해고예고 제도, 퇴직급여 보장법에 따른 퇴직금 제도, 출산전후휴가 및 육아휴직 등 모성보호 관련 규정, 재해보상 규정 등이 이에 해당한다.

(3) 주요 미적용 규정

- 반면, 소규모 사업장의 비용 부담이 큰 규정들은 적용에서 제외된다. 대표적으로 정당한 이유 없는 해고 등을 제한하는 규정, 부당해고 구제신청 규정, 연장·야간·휴일근로에 대한 가산수당 지급 의무, 주휴일을 제외한 연차유급휴가 규정, 근로시간의 제한(주 52시간제) 등이 적용되지 않는다.

2. 관련 판례

(1) 해고의 정당성과 절차

- 판례는 4인 이하 사업장의 경우 근로기준법 제23조 제1항의 해고 제한 규정이 적용되지 않으므로, 사용자가 정당한 이유 없이 근로자를 해고하더라도 그것이 민법상 신의칙 위반이나 권리남용에 해당하지 않는 한 유효하다고 본다. 따라서 노동위원회에 부당해고 구제신청을 할 수 없으며, 해고의 서면 통지 의무도 적용되지 않는다.

(2) 휴직 기간 중의 임금

- 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 지급하는 휴업수당 규정도 4인 이하 사업장에는 적용되지 않는다. 판례는 이러한 예외가 헌법상 평등권이나 근로의 권리를 본질적으로 침해하는 것은 아니라고 보아 합헌성을 유지하고 있다.

III. 적용제외

1. 근로기준법상의 예외

(1) 동거의 친족만을 사용하는 사업

- 사용자와 생계를 같이 하는 동거의 친족만을 사용하는 사업장에는 근로기준법이 전혀 적용되지 않는다. 이는 가족 간의 유대 관계를 고려하여 법이 가정 내의 사적인 영역에 개입하지 않으려는 취지이다. 다만, 동거하지 않는 친족이나 친족이 아닌 근로자가 단 1명이라도 포함되어 있다면 그 인원을 포함하여 상시 근로자 수를 산정하고 법이 적용된다.

(2) 가사 사용인

- 가정부, 유모, 집사 등 가구 내의 가사 업무에 종사하는 가사 사용인에게에는 근로기준법이 적용되지 않는다. 가사 업무는 근로 장소와 주거 장소가 혼재되어 근로시간과 휴게시간의 구분이 모호하고 감독이 어렵기 때문이다. 다만, 최근 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률이 제정되어 인증기관에 고용된 가사근로자에게는 별도의 보호 체계가 마련되었다.

2. 특별법상의 예외

(1) 선원법의 적용을 받는 선원

- 선원법의 적용을 받는 선원에게는 근로기준법의 근로시간, 휴게, 휴일 등에 관한 규정이 적용되지 않고 선원법이 우선 적용된다. 해상 노동의 특수성을 고려하여 선원법에서 별도의 근로조건을 규율하고 있기 때문이다.

(2) 기타 공무원 및 교원

- 공무원은 국가공무원법 및 지방공무원법, 사립학교 교원은 사립학교법 등이 우선 적용된다. 이들에게 근로기준법은 특별법에 규정이 없는 경우에만 한하여 보충적으로 적용되거나 적용이 완전히 배제되기도 한다.

IV. 결론

- 근로기준법의 적용범위는 상시 근로자 5인을 기준으로 전부 적용과 일부 적용으로 구분되며, 동거 친족이나 가사 사용인과 같은 특수한 경우에는 적용이 완전히 제외된다. 법의 실효성을 확보하기 위해서는 형식적인 사업장 구분보다는 실질적인 노무 관리의 독립성과 근로자의 종속성을 면밀히 검토하여야 한다. 특히, 소규모 사업장의 경우 일부 규정의 미적용으로 인해 근로자 보호의 사각지대가 발생할 수 있으므로, 판례와 행정해석은 근로자의 생존권 보장을 최우선으로 하여 법을 해석하고 적용하여야 한다. 사업주는 자신이 운영하는 사업의 상시 근로자 수를 정확히 파악하여 법적 의무 이행에 차질이 없도록 해야 하며, 노사 양측은 법의 테두리 안에서 신뢰와 협력을 바탕으로 합리적인 근로관계를 형성해 나가야 한다.